REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

così composta:

dr. Franca Mangano	Presidente
dr. Gisella Dedato	Consigliere relatore
dr. Riccardo Massera	Consigliere

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6606 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Parte_1 sito in via Podenzana n. 36/ via S. Maria della Speranza n. 5 Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Saraz Marco, come da procura in atti

APPELLANTE

E

Controparte_1, quale erede di *Persona_1* e *Controparte_2*, rappresentata e difesa dagli Avv. Berti Maria e Mancini Giulio, come da procura in atti

APPELLATO

E

CP_3, quale erede di *Persona_1* e *Controparte_2*, non costituito

APPELLATO

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15427/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5 novembre 2020

RAGIONI DELLA DECISIONE

Persona_1 e *Controparte_2* nella veste di comproprietari dell'unità abitativa (int. 8) sita nel condominio "*Parte_1*" di Via Podenzana, 36 / Via S. Maria della Speranza, 5 Roma, hanno impugnato,

innanzi al Tribunale di Roma, la delibera avente ad oggetto l'approvazione del "rendiconto gestione condominio 2017 e relativo riparto" (punto 1 dell'ordine del giorno) adottata il 30 maggio 2018 dall'assemblea condominiale, chiedendone l'annullamento.

A fondamento della domanda, gli attori, richiamando la perizia di parte redatta dal dott. *Per_2* in data 11 giugno 2018 ed allegata all'atto di citazione, hanno dedotto l'inintellegibilità del bilancio, per le seguenti ragioni: - presenza di voci privi di informazione (in particolare la voce "credito verso Amministratore precedente 110.308,10" contenuta nello stato patrimoniale, non essendo stato specificato che si trattava di un credito *sub iudice,* indebitamente preteso dal condominio nei confronti dell'ex amministratore, e la voce "Anticipazioni Amm." per € 14.465,13, non meglio precisata); - omessa indicazione nello stato patrimoniale della cassa contanti e del saldo bancario al 31/12/2017.

Gli attori hanno contestato ulteriori voci (spese di "gestione ordinaria", "riepilogo di cassa", "totale uscite" e "totale a pareggio"), senza tuttavia specificarne in modo puntuale le ragioni.

Il *Parte_1* di cui in epigrafe ha contestato la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: "*Definitivamente decidendo annulla la delibera con la quale l'assemblea del* *Parte_1* *convenuto in giudizio, in data 30-5-2018, ha approvato il documento costituito dallo 'stato patrimoniale' dell'ente di gestione allegato al consuntivo 2017. Condanna il convenuto a rifondere, in favore della parte attrice, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5400,00 di cui € 600,00 per spese vive comprensive del contributo unificato ed €4800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali*."

Il *Parte_1* di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: "*In via preliminare e pregiudiziale, accertata la tempestività e la fondatezza dell'eccezione di mancato espletamento, ovvero nullità, del procedimento di mediazione delegata da parte degli attori/appellati, revocare integralmente la sentenza appellata, dichiarando l'improcedibilità della domanda giudiziaria. - In via ulteriormente preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare, ex art. 163 e 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione, e per l'effetto, revocare integralmente la sentenza appellata. - In via ulteriormente preliminare gradata accertare e dichiarare il superamento dei limiti del thema decidendum in violazione dell'art. 112 c.p.c., accertando gli effettivi limiti della domanda e quindi confermare la legittimità dell'inserimento nella situazione patrimoniale del rendiconto consuntivo 2017 della posta contabile in contestazione e della relativa delibera di approvazione assunta, per l'effetto, previa revoca integrale della sentenza appellata, rigettare l'originaria domanda attorea. - In via meramente subordinata, e*

nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti eccezioni preliminari: accertare l'integrale legittimità, veridicità ed intellegibilità della rappresentazione contabile emergente dalla situazione patrimoniale allegata al Rendiconto consuntivo 2017, anche ex art. 441 C.p.c. nominando un Consulente Tecnico Contabile a tal fine. All'esito, accogliere il presente appello riformando integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare la legittimità della delibera assembleare assunta sul punto il 30.5.2018, con conseguente rigetto dell'originaria domanda attorea. - In tutte le ipotesi, con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio. - Condannando nel contempo gli appellati all'integrale restituzione del complessivo importo di € 7.049,38 ai medesimi corrisposto dal Parte_1 *a titolo di spese processuali di primo grado.".*

Controparte_1 si è costituita in giudizio, nella veste di erede di Per_1 [...] e di Controparte_2 , ed ha così concluso: " *per l'integrale rigetto per inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle tardive eccezioni e domande da controparte sollevate per la prima volta in grado di appello, come in narrativa individuate, nonché per l'integrale rigetto per inammissibilità ovvero infondatezza in fatto e diritto delle restanti domande spiegate in atto di appello; con integrale conferma dell'appellata sentenza; - in via subordinata, per l'integrale rigetto dell'avversario appello e delle deduzioni e domande tutte nello stesso spiegate, per radicale inammissibilità ovvero infondatezza in fatto e diritto, con integrale conferma dell'appellata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado, a carico dell'appellante."*

La causa, all'udienza del 7 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con il primo motivo di appello, intitolato "*a) Erronea applicazione in via analogica delle disposizioni di cui dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, in ordine alla tempestività dell'eccezione sollevata. b) Omesso avvio del procedimento di mediazione demandata da parte dell'attore* Per_1 *c) Nullità del procedimento di mediazione demandata incardinato dall'attrice sig.ra* CP_2 *d) Improcedibilità della domanda",* l' appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità dal medesimo sollevata con le memorie *ex* art. 183 c.p.c., in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria nei 15 giorni concessi dal giudice, o meglio in ragione dell'irregolarità del procedimento di mediazione per non essere stato introdotto da entrambi gli attori e per avere partecipato al procedimento il legale di Controparte_2 non munito di procura speciale sostanziale.

L'appellante ha dedotto che il termine di cui al citato art. 5 (" non oltre la prima udienza") entro il quale "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice l'omessa mediazione" si applica, per espressa previsione legislativa, esclusivamente al mancato

esperimento della procedura di mediazione preventivamente all'instaurazione dell' azione giudiziaria e non anche al reiterato mancato esperimento della mediazione successivamente disposto dal giudice in virtù della tempestività dell'eccezione sollevata.

La censura è fondata.

Si premette che ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.L. n. 28/2010, in tema di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza.

Ne consegue che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso alle parti e al giudice di rilevare l'improcedibilità nel corso del giudizio, così come, a maggior ragione, non potrà essere rilevata in sede di appello.

Sempre secondo il dettato della norma testé citata, nel testo applicabile ratione temporis, il giudice ove rilevi che la mediazione non è stata esperita fissa la nuova udienza, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Lo scopo della norma è quello di favorire gli accordi conciliativi, evitando, nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità in un'ottica di contemperamento dell'interesse deflattivo con il diritto ad una tutela effettiva.

Tanto premesso, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione nel termine dal medesimo concesso, così motivando: "*(..) questo giudicante, alla prima udienza, ha concesso il termine di legge per l'introduzione della mediazione. Alla successiva le parti hanno instato solo per la concessione dei termini ex art. 183 cpc mentre, unicamente alla successiva, parte convenuta ha sollevato l'eccezione, risultata quindi tardiva a mente dell'art. 5 del dlvo 28/10 che prevede che vada eccepita, a pena di decadenza, alla prima udienza (disposizione che è applicabile per analogia con riguardo all'ipotesi, verificatasi nel caso in esame, di mediazione su disposizione del giudice per cui il termine di decadenza deve ritenersi essere costituito dalla prima udienza utile). Mentre l'eccezione formulata in comparsa deve ritenersi superata dal provvedimento di concessione del termine da parte del giudice alla prima udienza (che ha rimesso 'in termini la parte onerata')."*

Osserva la Corte che, nel silenzio del legislatore, non può ritenersi esistente, ricorrendo all'interpretazione analogica, una barriera temporale per sollevare l'eccezione di improcedibilità, ovvero per il rilievo d'ufficio, nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la mediazione obbligatoria disposta dal giudice, e, pertanto, non può ritenersi, su tale via, che il rilievo d'ufficio

e/o l'eccezione non siano consentiti nel corso dell'intero giudizio di primo grado e anche in appello, sul presupposto che anche in tale ipotesi, al pari del mancato esperimento della procedura di mediazione preventivamente all'instaurazione dell'azione giudiziaria, sussista l'esigenza di salvaguardare, attraverso lo strumento della decadenza, l'attività giurisdizionale svolta o meglio l'esigenza di evitare la dispersione dell'attività del giudice e delle parti in un'ottica di economia processuale, quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto ed efficiente processo e della sua ragionevole durata.

Una diversa interpretazione, basata sulla possibilità di applicare analogicamente la barriera temporale prevista per sollevare l'eccezione o per il rilievo d'ufficio nell'ipotesi di mancato esperimento della procedura di mediazione preventivamente all'instaurazione del giudizio, si porrebbe in contrasto con il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali *ex* art. 14 preleggi, nel novero delle quali si inseriscono le norme dettate in materia di decadenza, per derogare al principio generale secondo il quale l'esercizio dei diritti soggettivi non può essere soggetto a limiti.

In sostanza, le norme che prevedono termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione oltre i casi espressamente considerati, anche ove dovesse ravvisarsi la necessità di tutelare la medesima esigenza. (in tal senso, Cass. sentenza n. 8350/2012).

Osserva ulteriormente la Corte che, in ogni caso, non vi sarebbe stato spazio per l'interpretazione analogica, in quanto il ricorso ad essa presuppone una lacuna normativa, che, nel caso di specie, non si rinviene, per come meglio si dirà nel prosieguo, dopo aver illustrato i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 12, comma 2, disposizioni preliminari (c.d. preleggi), quando una controversia non può essere decisa con una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo i canoni dell'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica – il giudice ricorre all'analogia *legis*, ovvero estende al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe. E se, ciò nonostante, permane il dubbio interpretativo, troverà applicazione l'analogia *iuris*, ossia l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In tal modo, il ricorso all'analogia si risolve in un meccanismo integrativo dell'ordinamento che permette al giudice di decidere comunque, anche in presenza di una lacuna normativa.

L'interpretazione per analogia è costituita dunque dal procedimento mediante il quale chi interpreta ed applica il diritto può sopperire alle eventuali deficienze di previsione legislativa (c.d. lacuna dell'ordinamento giuridico) facendo ricorso alla disciplina normativa prevista per un caso "simile", ovvero per "materie analoghe": ciò, in forza dei principi fondamentali del nostro

ordinamento, secondo cui il giudice deve decidere ogni caso che venga sottoposto al suo esame ("obbligo di non denegare giustizia") e deve assumere la relativa decisione applicando una norma dell'ordinamento positivo ("obbligo di fedeltà del giudice alla legge" *ex* art. 101, comma 2, Cost.). (in tal senso, Cass. sentenza n. 16634/2005).

Segnatamente, quindi, per poter ricorrere al procedimento per analogia, è necessario che: 1) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; 2) sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia *legis*) o uno o più principi giuridici (c.d. analogia *iuris*), il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla situazione originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata: costituendo il fondamento dell'analogia la ricerca del *quid* comune mediante il quale l'ordinamento procede alla propria "autointegrazione" .

Onde l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una "lacuna", tanto che al giudice sia impossibile decidere, secondo *l'incipit* del precetto («se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione ...»); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un *non liquet*, a causa la mancanza di norme che disciplinino la fattispecie.

La regola, secondo cui l'applicazione analogica presuppone la carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un caso (art. 14 preleggi), discende dal rilievo per cui, altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa alla discrezionalità giuridica dell'organo giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato.

Tuttavia, il fatto che una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, non costituisce *ex se* una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia.

Ciò tanto più quando si tratti di estendere l'applicazione di una disposizione specifica oltre l'ambito di applicazione delineato dal legislatore, ovvero di applicarla "analogicamente" a vicenda concreta da questi non contemplata ed in presenza di diversi presupposti integrativi della fattispecie. (Cass. Sez. Unite sentenza n. 38596 del 6 dicembre 2021; Cass. sentenza n. 16634/2005).

Seguendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, che, nel caso di specie, il ricorso all'analogia non sarebbe stato comunque possibile, proprio in quanto non sussiste una lacuna normativa da colmare necessariamente, per evitare il *non liquet*, ma piuttosto il legislatore, non prevedendo alcun termine di decadenza per sollevare l'improcedibilità nell'ipotesi in cui la parte onerata non vi abbia

provveduto nel termine concesso dal giudice, ha espresso una precisa volontà di sanzionare con l'improcedibilità, non più sanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo, l'inerzia dell'attore che, pur espressamente invitato ad instaurare il procedimento di mediazione, non vi abbia ottemperato o vi abbia ottemperato malamente, così dimostrando di non avere alcun interesse di tentare la strada della mediazione.

In sostanza, la mancata previsione di un termine di decadenza non può mai costituire un vuoto normativo, da colmare attraverso l'applicazione di una norma che, nel regolare un caso simile, lo preveda, in quanto è da ricondursi ad una precisa scelta legislativa, anche tenuto conto della natura eccezionale del regime delle decadenze.

Per quanto fin qui detto, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la condizione di procedibilità si era verificata ed in caso negativo dichiarare l'improcedibilità.

Tale riscontro verrà eseguito, quindi, in questa sede.

Controparte_2 rappresentata in giudizio dagli Avv.ti Maria Berti e Giulio Mancini, non ha partecipato personalmente alla mediazione, essendo stata rappresentata dall'Avv. Maria Berti, con l'assistenza dell'Avv. Giulio Mancini.

La rappresentante, Avv. Maria Berti, non era munita di una procura speciale e sostanziale *per disporre dei diritti oggetto della controversia.*

Il legale può rappresentare una parte nella mediazione solo se dispone di una procura che lo autorizzi a partecipare alla procedura di mediazione e gli conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali della controversia, donde per una valida rappresentanza non si può prescindere dal conferimento di una procura speciale e sostanziale**.**

In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, secondo cui "*La parte (….), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche- ma non solo – dal suo difensore.*

Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia." (Cass. sentenza n. 8473/2019).

Sulla stessa scia si colloca la più recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 18106/2024), che ha ribadito l'improcedibilità della domanda se l'avvocato rappresenti la parte in mediazione senza una specifica procura sostanziale, che non si identifica con la mera procura alle liti conferendo quest'ultima solo il potere del legale di rappresentare la parte in giudizio e di compiere atti processuali, non includendo il potere di

disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite.

La Suprema Corte, in sostanza, ha ribadito che solo la procura sostanziale rende la partecipazione alla procedura conciliativa effettiva, sottolineando che la mancata partecipazione personale delle parti o di un rappresentante dotato di procura sostanziale compromette la validità del tentativo conciliativo.

D'altronde, se l'obiettivo della mediazione è di favorire un contatto diretto tra le parti e il mediatore, al fine di intraprendere un dialogo informale che consenta loro di esplorare soluzioni conciliative prima di irrigidirsi nelle rispettive posizioni processuali, non può la delega all'avvocato o a un altro rappresentante non essere supportata da una procura sostanziale.

Ed invero, la mancanza di tale procura, precludendo *ab origine* l'esito positivo della mediazione, non potendo il legale, per l'appunto, disporre dei diritti in un'ottica conciliativa, evidenzia la volontà della parte di adempiere solo formalmente all'obbligo del tentativo di conciliazione, senza, dunque, la volontà di tentare di comporre realmente la controversia.

Opinando diversamente verrebbe ad essere compromesso lo spirito della mediazione, trasformandola in un mero adempimento formale.

Per quanto fin qui detto, deve ritenersi che, nel caso in esame, la mediazione, in difetto della procura sostanziale all'Avv. Maria Berti, non può considerarsi validamente ed efficacemente espletata, ne segue l'improcedibilità della domanda.

In disparte, si osserva che avendo attivato la mediazione, sia pure invalidamente, solo *Controparte_2* e non anche *CP_4*, nei confronti di quest'ultimo si sarebbe dovuta comunque dichiarare l'improcedibilità, esaminando il merito solo con riferimento alla posizione dell'attrice, *Controparte_2* - e ciò sarebbe stato possibile non vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario (la delibera condominiale può essere impugnata anche da uno solo dei comproprietari) - in quanto, nel silenzio del legislatore, l'obbligo di partecipare alla mediazione grava su tutti gli attori, senza che la presenza dell'uno possa sostituire quella degli altri o implicare una tacita delega a trattare con la controparte.

Per quanto fin qui detto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, deve essere dichiarata improcedibile la domanda.

Deve essere accolta la domanda proposta dal condominio di cui in epigrafe volta ad ottenere la restituzione dell'importo di € 7.049,38 corrisposto a *CP_3* e a *Controparte_1* per la causale "spese legali sentenza n 15427/2020" in data 13.11.2020 a mezzo bonifico bancario, come da documentazione versata in atti.

Ed invero, il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza, che trova il suo fondamento nella norma di cui all'art. 336 c.p.c., sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni di cui alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.

Su tale somma spettano gli interessi legali dal giorno del pagamento, anche in difetto di espressa domanda, in virtù del principio secondo cui il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, non dà luogo ad una *condictio indebiti*, ma dà diritto al *solvens* di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente, restando pertanto irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'*accipiens* (Cass. 21.4.2010 n. 9480).

Le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55/2014 (valori medi dello scaglione valore indeterminabile -complessità bassa-, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata).

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 15427/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5 novembre 2020, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda proposta da *Persona_1* e *Controparte_2* a cui sono subentrati, *iure hereditatis*, *Controparte_1* e *CP_3*
- condanna *Controparte_1* e *CP_3* a rimborsare al condominio "*Parte_1*", sito in via Podenzana n. 36/ via S. Maria della Speranza n. 5 Roma, la somma di € 7.049,38, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna *Controparte_1* e *CP_3* al pagamento delle spese di lite, in favore del condominio "*Parte_1*" sito in via Podenzana n. 36/ via S. Maria della Speranza n. 5 Roma, che

liquida, per il giudizio di primo grado, in € 5810,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., e per il presente giudizio, in € 6.946,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Gisella Dedato

Il Presidente

Dott.ssa Franca Mangano